

1500420-20.2021.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... no bairro porque na praça ocorre intenso tráfico de drogas. Avistaram dois indivíduos. O "beijo" correu e adentrou num centro comercial, retirando a camisa. Encontraram a droga no local onde o réu mexia. O outro, aparentemente ia comprar o entorpecente. O réu era visto no local e havia suspeita de que ele estava participando do tráfico. Havia mais pessoas no local, pessoas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500420-20.2021.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500420-20.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2137064/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 18024306 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 438/21/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2137064 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 438/21/200 -

DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO MARCELO APOLINARIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida em desfavor de Paulo Marcelo Apolinário, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, c.c o artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, eis que no dia 19 de maio de 2021, por volta das 17h15, na Praça João Batista Ribeiro de Lima, Vale do Redentor, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 64 (sessenta e quatro)

cápsulas contendo cocaína, com peso líquido de 12,2 gramas e 52 (cinquenta e dois) invólucros plásticos contendo cocaína, em forma de "crack", com peso líquido de 5,82 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia de págs. 149/151 veio amparada no Inquérito Policial – Prisão em Flagrante – de págs. 01/20.

Concedida Liberdade Provisória diante da ausência de requerimento de prisão preventiva, conforme decisão de págs. 55/58.

O réu foi notificado (pág. 159) e apresentou defesa preliminar (págs. 164/167), requerendo a absolvição do acusado por não existir prova suficiente para a condenação.

A denúncia foi recebida aos 20 de abril de 2022 e foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (págs. 170/172).

Durante referida solenidade foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório do acusado, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada no SAJ – pgs. 236/238.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi requerido.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público requer a procedência da denúncia. Destaca que havia 116 porções de cocaína. O réu negou em juízo e permaneceu em silêncio na delegacia. Não foi arrolado como testemunha a pessoa que teria vendido o salgado para o réu. Os policiais disseram que chegando o local, há muito conhecido como ponto de tráfico, viram o réu em movimentação típica de traficância. O réu estava agachado, pegando algo no chão. Nada indica que os réus viriam a juízo mentir com o propósito de incriminar o réu. Os policiais disseram que viram o réu mexendo no chão, no local onde encontraram a droga. A testemunha Ricardo demonstrou que não queria se envolver no tráfico. O local é amplamente conhecido dos policiais e do Juízo como ponto de venda de drogas. O testemunho de Ricardo não auxiliou nem a defesa, nem a acusação. Por outro lado, o testemunho dos policiais incrimina o réu, pois não havia qualquer outra pessoa nas imediações dos fatos. O acusado ostenta Maus antecedentes e é reincidente específico. Requer o aumento da pena base pela apreensão de 116 porções de cocaína. Na segunda fase merece nova majoração pela reincidência específica. Pugna pela incidência da causa de aumento de pena capitulada na denúncia, pois o local também fica próximo de uma escola, campo de bocha e parque infantil, destinados a diversão de qualquer natureza. Requer o regime fechado, sem substituição.

A defesa requer a absolvição do réu, pois não há provas suficientes para a condenação. Não há filmagens e nada que prove que o réu estava com outro indivíduo. Foi visto adentrando num bar e tinha consigo apenas R\$ 12,00. Ressalta que não havia elementos para a prisão do réu na audiência de custódia. Os fatos se passaram há mais de um ano e o réu reside no próprio bairro, local de entretenimento. Durante a noite está tudo fechado, abandonado. O réu frequenta o ponto porque há barbeiro e outros estabelecimentos. O réu está trabalhando e mora nas imediações. O outro indivíduo nem identificado foi e não se pode concluir que a droga pertencia realmente ao réu. O réu não foi visto entregando drogas e na data do flagrante não há indicação de que o réu estivesse agachado no local, o que gerou o relaxamento do flagrante do réu que permanece até hoje trabalhando e frequentando a praça como as pessoas que moram ali. Reafirma que o réu apenas estava passando no local para se alimentar, ingerir bebida e conversar com moradores do bairro. Nas pgs. 53/54 do feito há as razões pelo relaxamento da prisão. O réu desconhece a origem e nega a propriedade da droga. Nesse liame, salienta que o réu tem residência fixa e

ocupação lícita, trabalhando na entrega de verduras. O réu não pode ser responsabilizado pela traficância pelo entorpecentes encontrado em local público, abandonado. Não há provas de que o acusado tivesse a intenção de vender drogas. Diante da insuficiência de provas não há como imputar ao réu a autoria da traficância, devendo o réu ser beneficiado pela dúvida. Em caso de condenação, requer o direito de apelar em liberdade.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão que acompanha o flagrante (págs. 07/08), autos de constatação preliminar (pág. 09), Laudos Periciais de págs. 107/109 e 110/112, além das demais provas produzidas nos autos.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

1.2 -) Das provas da autoria.

Rivaldo Luciano Tonhão informa que o local é a praça do Vale, biqueira mais antiga de São José do Rio Pardo e viram o réu agachado no local e um indivíduo ao lado. O réu estava mexendo no chão. O "beijo", alcunha do réu, adentrou num bar e tirou a camiseta e tentou misturar-se com os frequentadores do bar. Retornaram ao local onde o réu estava mexendo, encontraram as drogas. O réu era suspeito, bastante conhecido e frequentava o local. Ele continua na mesma função na praça e nada mudou. Ele negou a propriedade da droga. O outro indivíduo não foi identificado. Quando deparou-se com os dois indivíduos, o réu estava agachado mexendo no chão e o outro rapaz como se estivesse esperando para pegar a droga. A conclusão é a de que o réu estava traficando porque ele é quem estava mexendo no chão. A praça é ponto antigo de tráfico de drogas. A conduta ali é comum. 90% das prisões lá é assim. Eles escondem nas moitas ou enterram. Não há dinheiro. Havia apenas R\$ 12,00 com ele. Ou o recolhe passa antes pegando ou eles costumam esconder. A praça é 24 horas movimentada. Muita gente jogando carta, jogando "bocha" e tem uma escola nas proximidades, em frente ao bar onde ocorreu os fatos. A escola é a Laudelina. Tem um parquinho, do lado. Tudo faz parte do conjunto da praça. O acusado continua sendo visto no local, na mesma situação. Não conseguiram surpreendê-lo em nova traficância. Ele fica lá diuturnamente.

João Paulo Gonçalves Parra relata que a equipe estava em patrulhamento no bairro porque na praça ocorre intenso tráfico de drogas. Avistaram dois indivíduos. O "beijo" correu e adentrou num centro comercial, retirando a camisa. Encontraram a droga no local onde o réu mexia. O outro, aparentemente ia comprar o entorpecente. O réu era visto no local e havia suspeita de que ele estava participando do tráfico. Havia mais pessoas no local, pessoas jogando bocha. Mas, eles estavam destacados dos demais. O primeiro contato visual deu-se a uma distância máxima de uns 20 metros. O réu era suspeito por envolvimento com tráfico. Não sabe onde o réu mora. Viu o réu por ali em outras ocasiões. Ele guardava droga ali. Não havia mais ninguém por perto. Na praça tem um parquinho e o centro comercial. Ali tem a bocha e ponto de ônibus e a escola Laudelina. Os traficantes ali ficam na barraca da Nilva e quando o comprador chega eles vão até uma árvore, até onde esconderam a droga. Ele foi preso com apenas R\$ 12,00 porque provavelmente haveria mais alguém

auxiliando na venda, segurando o dinheiro.

Ricardo Alexandre Barbosa disse que no momento da abordagem, o réu estava de fora do seu comércio. Ele correu para dentro do balcão e pulou lá dentro. Ele foi abordado dentro do comércio e lá não foi encontrado nada. Do lado de fora não sabe se foi encontrado algo. Conhece o réu como morador do bairro. Ele mora uns 3 ou 4 quarteirões para baixo da praça. Depois que a polícia saiu não sabe se eles acharam drogas. No bar estavam em 3 pessoas e na praça não tinha muita gente não. Mas, não dava para ver o fundo da praça. Se ocorre tráfico de drogas ali na praça é na parte de fora. O depoente não sabe se ocorre tráfico lá. Na praça tem um parque infantil do lado de trás e a parte do fundo dos banheiros de uma escola dá para o parquinho. A escola é a Laudelina. O réu está trabalhando com verdura. Ele era cliente do bar. Entrava pegava o que consumia, pagava e saía. Para o depoente ele era um trabalhador comum. A iluminação da praça sempre foi precária.

O acusado, Paulo Marcelo Apolinário, já foi preso por artigo 157 e tráfico. Fazia 4 meses que estava na rua. Tem 45 anos. Trabalha com verduras. Tem filho, mas não é casado. Não usa drogas. Ouviu o que os policiais disseram e entendeu. Tinha acabado de chegar na barraca para comer um salgado. Entrou no centro comercial porque ficou com medo, tinha ficado preso seis anos. Não sabe nada da droga e está trabalhando, graças a Deus. Chega de madrugada e vai na praça comer um salgado. Mora ali perto, na rua debaixo da praça. É o único lugar que tem para comer um salgado. Não foi vista agachado conversando com ninguém. Chegou com R\$ 20,00, comeu um salgado e tomou um guaraná e sobraram R\$ 12,00. Mostraram a droga para o depoente, mas não era sua. Não tem nada a ver com a droga. Não viu onde acharam a droga. Vieram com a droga para o seu lado, falando que a droga lhe pertencia. Fazia uns 15 a 20 minutos que estava por ali, comendo o salgado. Quer dizer que é inocente. Está trabalhando e correu para não ir preso. Ninguém vê o depoente na rua. Está tranquilo da vida do crime porque "não vira nada", "só lhe deu prejuízo".

2 -) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois "goza de presunção de credibilidade".

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que "toda pessoa pode ser testemunha", logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que contemplar violação ao princípio da

igualdade tratando diversamente o valor de uma testemunha por sua profissão, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada.” (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

A perfeita identidade entre as versões, tal como se vê em solo policial e depois em Juízo, é reconhecida pela jurisprudência como fator hábil a dar validade à prova testemunhal policial.

A bem da verdade, consta que em patrulhamento na altura da praça João Batista Ribeiro de Lima, no bairro do Redentor, nesta cidade, os policiais militares avistaram o popular “Beicho”, depois identificado como sendo Paulo Marcelo Apolinário, que na ocasião comercializava drogas com um usuário. Ao perceberem a aproximação da equipe policial, dispersaram-se. O usuário não foi localizado e nem identificado. Ao realizarem o acompanhamento de Paulo, a equipe verificou que ele adentrou um estabelecimento comercial existente na praça. Ao ser abordado ele foi algemado e realizada busca pessoal, sendo localizado a quantia de R\$ 12,00 reais. Em seguida, a equipe retornou ao local onde o réu encontrava-se anteriormente, sendo localizado 64 “eppendorfs” de cocaína, com peso aproximado de 62,14 gramas e 64 pedras de crack, com peso aproximado de 9,98 granas.

Nos depoimentos de pgs. 02 e 03, prestados em solo policial, os militares categoricamente teriam dito que o réu estava em ato de comercialização de drogas. Nada faz crer que os policiais pudessem ter consigo 64 (sessenta e quatro) porções

de cocaína e 52 (cinquenta e duas) porções de crack para indevidamente "forjar" cidadão, colocando suas carreiras em risco a fim de aprisionar pessoa com a qual não mantém qualquer desafio ou problema pessoal. Os policiais em questão são experientes e sabem bem diferenciar atos de entrega de entorpecente de mera conversa entre frequentadores da praça. Os policiais indicaram o réu e não qualquer outra pessoa como sendo aquela avistada mexendo exatamente no local onde as drogas foram deixadas.

A dúvida capaz de favorecer o réu deveria estar sustentada em contraprovas e não meramente a partir de argumentações e negativa de autoria, sob pena de contemplar-se indevidamente a subjetividade e o "decisionismo".

Nesse sentido, os ensinamentos de FRAMARINO DEI MALATESTA, o qual afirma que "o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 - destaque do Juízo).

À míngua de contraprovas que possam evidenciar que os policiais militares tenham se equivocado na análise dos fatos corriqueiros à sua profissão, resta ao Juízo cancelar a tese vertida na proemial acusatória, eis que ausente qualquer dúvida razoável capaz de beneficiar o réu.

Com tais fundamentos, fica afastada a tese defensiva de insuficiência probatória e adequação do benefício do favor rei ao caso sub apretiationis.

Todavia, a denúncia não procede na imputação da causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006.

A denúncia situa os fatos na Praça João Batista Ribeiro de Lima.

Não se pode emprestar qualquer amplitude ao termo "praça" para confundi-lo com "recinto onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza", pois com apoio léxico tem-se que "recinto é local cercado ou fechado" (Dicionário Aurélio, Ed. Positivo, 3.ed, 2004, vocábulo "recinto" p. 1709).

Ao contrário de "recinto", uma praça é um local geralmente amplo e aberto, bem de uso comum. Aumentar a pena neste caso seria proceder com clara analogia in malam partem.

Há praças de maiores ou menores dimensões espalhadas pelo centro e bairros da cidade. Apenas na parte central são vizinhas e quase contíguas as praças do Epidauro; a praça dos 3 Poderes e a praça Cândido Ribeiro, todas circundadas por escolas nas adjacências.

A cidade de São José do Rio Pardo é relativamente pequena. Tem cerca de 55.000 habitantes. Como dito acima, existem diversas praças, escolas, locais de atendimento público espalhados pela urbe, de modo que encampar a tese ministerial também ocasionaria que em praticamente todos os tráfegos de entorpecentes nesta cidade ensejassem a incidência da majorante em verdadeira e inaceitável aplicação de responsabilidade penal objetiva, violando o finalismo penal. Estariam livres apenas, em tese, traficantes que se utilizassem da zona rural.

Assim, o fato de que o réu tenha sido avistado em uma "praça" não autoriza a exasperação de pena na forma pretendida pelo Ministério Público, uma vez que não se trata de "recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza".

Embora na audiência de instrução o DD. Promotor de Justiça tenha feito pertinentes indagações a respeito das proximidades de uma escola, um parque infantil e um campo de bocha, tais circunstâncias não estão descritas na denúncia e sua admissão para fins de exasperação da pena representaria violação ao princípio da correlação ou congruência, corolário da ampla defesa e devido processo legal.

Some-se a isso o fato da infração ter se consumado durante a pandemia da Covid-19 (a pena será agravada por isso), momento em que, dadas as regras de restrição à circulação social, não é possível presumir que a praça, por si só, seja um local de maior aglomeração de pessoas.

A praça em questão, aliás, é local frequentado por usuários de droga e diversos traficantes (fato público e notório), o que inibe a presença de populares em seu entorno.

O mesmo entendimento prevaleceu perante a 11ª Câmara de Direito Criminal em voto de relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Paiva Coutinho na apelação criminal 0000713-69.2018.8.26.0575 desta mesma vara, julgada aos 04.03.2021.

Presente a tipicidade delitiva na forma básica da *fattispecie* e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia de págs. 149/151 para CONDENAR PAULO MARCELO APOLINÁRIO pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, passando a dosar-lhe as penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o *modus operandi* não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Cabe ressaltar, ainda, a exasperação também não é medida a se impor, neste caso, em relação à natureza das drogas. Crack, cocaína e maconha são entorpecentes considerados "comuns" encontrados em qualquer cidade e apreendidos com frequência diária em São José do Rio Pardo.

A interpretação da Lei Penal exige que este Juízo considere que apenas substâncias excepcionais como ópio, LSD, ecstasy, heroína, poderiam justificar a majoração da pena com base na natureza do entorpecente.

Na análise determinada pelo art. 42 da Lei de Drogas tem-se que o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não recomenda acréscimo, pois a apreensão foi de 12,2 gramas de cocaína e 5,82 gramas de cocaína em forma de "crack" (massas líquidas indicadas nas pgs. 107/112).

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Analisando os itens o Juízo encontra campo para ligeiro acréscimo, uma vez que o réu mantinha a posse de duas espécies de entorpecentes. Assim, poderia atingir "clientela" mais diversificada, ostentando maior periculosidade do que o traficante que tem consigo um único tipo de entorpecente.

O motivo do delito se constitui pela vontade de locupletar-se com a venda de entorpecente o que já está albergado no próprio tipo legal.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

O réu ostenta maus antecedentes, pois condenado definitivamente nos autos do processo » Foro de São José do Rio Pardo - 2ª Vara. Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo: 0004239-98.2005.8.26.0575 (0004239-98.2005.8.26.0575), trânsito em julgado aos 04.04.2008.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, na proporção de 2/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

O réu é reincidente específico. Além da condenação supra também foi condenado definitivamente nos autos dos processos » Foro de São José do Rio Pardo - 1ª Vara. Ação Penal - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0004233-42.2015.8.26.0575 (0007068-12.2016.8.26.0496) - trânsito em julgado para a defesa em 27.06.2017 - pg. 21/22.

Presente, ainda, a agravante do artigo 61, II, "j" do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido em período de calamidade pública, declarada pelo Governo Federal e Estadual em decorrência da pandemia do Covid-19.

Registre-se que há total pertinência entre a incidência desta agravante e a situação de calamidade em vigor. Vivemos uma calamidade pública sanitária, encontrando-se a saúde pública enormemente fragilizada, com milhões de infectados pelo coronavírus e centenas de milhares de mortos (mais de seiscentos mil nesta data).

O tráfico de drogas é conduta que ataca exatamente a saúde pública e na época dos fatos 19.05.2021 a ampla campanha de vacinação sequer havia tomado fôlego inicial.

Indesculpável que o réu, insensível à realidade calamitosa experimentada pela cidade de São José do Rio Pardo, pelo país e pelo mundo, pretendesse vender mais de uma centena de porções de droga (cocaína e crack) nesta cidade.

Ademais, não se extrai do disposto na alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal, qualquer outra exigência senão a da prática do crime em situação de calamidade pública.

A voluntas legis foi de, sabiamente, agravar a pena daqueles que a despeito de uma situação de calamidade, atacam o rigor da norma penal avançando sobre bens jurídicos alheios, individuais, difusos ou coletivos.

Assim, novo acréscimo se impõe a fim de que a pena seja alçada ao patamar de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 888 dias-multa.

Descabida a minorante do § 4º do art. 33 diante dos maus antecedentes e reincidência.

À míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena torno em DEFINITIVA apenas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 888 dias-multa.

Quanto ao regime prisional deve ser o inicialmente FECHADO, pois mantido o caráter hediondo da conduta. Além disso, o réu é reincidente específico e ostenta maus antecedentes, tendo experimentado condenação no mesmo regime e não se ressocializou. Destarte, a imposição de regime menos rigoroso mostra-se claramente inadequada ao perfil do réu.

Permito que recorra em liberdade, pois assim respondeu ao processo e não se fazem presentes os requisitos para sua custódia cautelar atualmente.

Nos termos dos artigos 804 e 805 do CPP, sucumbente em parte, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 50 UFESP's. Ressalte-se que o réu está patrocinado por advogado dativo. Assim, defiro-lhe os benefícios da assistência judiciária, ficando a cobrança suspensa na formado § 3º do art. 98 do NCPC c/c art. 3º do CPP.

Patrocinado por advogado dativo, honorários na forma do convênio OAB-DPE.

Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ22. 04.03, p. 253).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeça-se mandado de prisão guia de execução definitiva. O réu deverá ser apresentado para regular audiência de custódia quando houver o cumprimento do mandado de prisão, observando-se as prescrições regulamentares inerentes.

Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;

Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, pois à míngua de comprovação de origem lícita estão claramente vinculados à mercancia de entorpecentes ilegal desempenhada pelo réu.

Nos termos do art. 72 da Lei de Drogas, proceda-se à destruição do entorpecente mantido para fins de contraprova.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA